

1500636-20.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... em relação à autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente; de rigor., portanto, operar a desclassificação" (Apelação Criminal nº 990.09.174232-5, São Paulo, rel. Antonio Manssur, j. 15.12.2010)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06)- POSSIBILIDADE - AUSENTES EVIDÊNCIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500636-20.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500636-20.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DONATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Vistos.

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DONATO, qualificado às fls. 05/06, está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 17h20min, na Rua Mendes de Moraes, n.º 857, Jardim Itapura, nesta cidade e comarca, DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DONATO, qualificado às fls. 05/06, trazia consigo 06 (seis) porções de cocaína em forma de crack, pesando aproximadamente 7,76 gramas (sete gramas e setenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, fotografias de fls. 38/39 e laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 88/90. Segundo apurado, o denunciado trazia consigo o entorpecente acima, já fracionado para imediata comercialização,

próximo a estabelecimento comercial frequentado por dependentes químicos. Sucede que, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita, o qual ao avistar a viatura correu em direção ao chamado Bar do Piauí, onde descartou a droga. O denunciado foi abordado e apreendida a droga por ele dispensada, consistente em 06 (seis) porções de cocaína em forma de crack, pesando aproximadamente 7,76 gramas (sete gramas e setenta e seis centigramas), além de um aparelho de telefone celular, uma lâmina para preparar a droga e a quantia de R\$ 61,00 (sessenta e um reais) em dinheiro, fruto da mercancia ilícita, sendo preso em flagrante. O laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 88/903 atestou a presença da substância entorpecente cocaína nos invólucros trazidos pelo denunciado. As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à quantidade de droga apreendida, a forma como cada porção estava dividida e armazenada, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga seria destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes." Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentaram defesas preliminar (fls. 115/118), sobre as quais o Ministério Público se manifestou (fls. 122), o despacho de fls. 124/128, de 23 DE SETEMBRO DE 2002, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça pediu a desclassificação da imputação feita para denúncia para o delito de porte de droga para consumo pessoal e a fixação da pena de prestação de serviços à comunidade. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor do réu, pediu a absolvição por falta provas e desclassificação da imputação para o delito de porte de droga para consumo próprio e imposição de pena de advertência.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputado ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls.22/23; pelo laudo químico de fls. 108/110, que afirmou: "Item Único (Acondicionado sob o lacre 020444 ) Descrição: Um invólucro(s) plástico(s) encerrando (1) uma lâmina de metal com um furo em seu centro, como a encontrada em apontador de lápis, medindo 2,3 cm de comprimento, 0.6 cm de largura e 0.1 cm de espessura com um lado cortante, tendo sido efetuado líquido de lavagem para análise. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0091926 Ano 2022; além da prova oral carreada para os autos.

A ocorrência dos fatos como narrados na denuncia e apreensão das drogas em poder do réu, como afirmados na denúncia também restaram suficientemente demonstrados nos autos.

Os PMS. Que realizaram a diligencia confirmam que em razão do réu ter saído em fuga quando avistou a policia, conseguiram segui-lo e viram ele se livrando de algo. Depois encontraram e constaram que era a droga, a lâmina e o dinheiro apreendido nos autos.

O réu confessou a posse da droga, do dinheiro e da lâmina, apreendidos nos autos, mas afirmou que destinava ao seu uso próprio.

Esse conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a prática do delito de porte de droga para consumo próprio, como bem reconheceu o Ministério Público e pleiteou a douta Defesa.

Em casos semelhantes, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já decidiu: "Tráfico de drogas - Fragilidade da prova referente à destinação do entorpecente ao comércio - Desclassificação para posse de drogas em razão da comprovação da apreensão do entorpecente em poder do apelante - Inteligência do art. 28, da Lei nº 11.343http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-t%C3%B3xicos-lei-11343-06/06 - Recurso da Defesa parcialmente provido com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva" (Apelação criminal nº. 0008679-51.2009, Salto,

rel. Alexandre Almeida, j. 13.4.2011).

"E, ainda que tivesse o apelante admitido a propriedade da droga, na fase judicial, afirmou que se destinava a consumo próprio, negando o tráfico, o que há de ser recepcionado, pois, em realidade, nenhuma prova se fez em sentido contrário, ou seja, que houvesse o intuito de entrega ou fornecimento a terceiros, mormente se confrontada a conduta assumida com os elementos de convicção trazidos aos autos, não havendo possibilidade, assim, de manter-se, o decreto condenatório, com fulcro no art. 33 da Lei nº 11.343/06, mesmo porque, ante a gravidade dos fatos deduzidos na inicial e considerado que a resposta penal para o delito imputado é por demais severa, se exige, como manifesto, prova límpida e estreme de dúvida, em relação à autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente; de rigor., portanto, operar a desclassificação" (Apelação Criminal nº 990.09.174232-5, São Paulo, rel. Antonio Manssur, j. 15.12.2010)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06)- POSSIBILIDADE - AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DA MERCANCIA. Cabível a desclassificação para o crime de posse de tóxicos para consumo pessoal quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por tráfico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-SP - APL: 00021751520168260322 SP 0002175-15.2016.8.26.0322, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 08/06/2017, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2017).

A apreensão de pequena quantidade de droga, bem como a ausência de investigações em curso, a demonstrar suspeita de mercancia ilícita de entorpecentes, e a falta de abordagem de suposto adquirente são indicativos de que a droga era para consumo próprio. Ausente a prova incontestada do tráfico, correta a desclassificação da infração para uso próprio. Não é suficiente a probabilidade do cometimento do delito. A dúvida acerca da destinação das drogas apreendidas se revolve em favor das rés.

Desclassificação a imputação que a denúncia faz as rés para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

A subsistência do caráter criminoso da conduta porte de droga para consumo pessoal se justifica pela lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade e saúde públicas.

A lei não pune, contudo, o consumo da droga (se o fizesse o tipo seria inconstitucional); incrimina-se, tão somente, o ato de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo (para consumo pessoal) drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E é nessas situações que o comportamento do agente vulnera o bem tutelado na norma incriminadora, tendo em conta as propriedades maléficas da droga e a potencial disseminação desses malefícios na sociedade.

O artigo 28, da Lei 11.343/06, cuida de infração de mera conduta, não se fazendo mister nenhum perigo concreto ao bem jurídico.

Já que trata de mera infração "sui generis", não sendo a prisão a pena cominada, pode-se transigir com as exigências emanadas do princípio da ofensividade (lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico).

Tal como ressaltado, a coibição legal do uso de drogas não se destina somente ao usuário, vai além, impede a proliferação dos malefícios das substâncias entorpecentes para a coletividade e para a saúde pública, sendo típica a conduta.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da natureza jurídica da conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo, por conseguinte, a constitucionalidade da criminalidade do uso de entorpecente, confira-se:

"POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL:(ART. 28 DA L. 11.343/06 - NOVA LEI DE DROGAS): NATUREZA JURÍDICA DE CRIME - 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que Lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela Lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da

L.11.343/06, partir de um pressuposto desprezo do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L.11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao USO da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95(art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: Consumação, à vista do art. 30 da L.11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE-QO 430105 -RJ - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 27.04.2007).

Frise-se, por oportuno, o princípio da insignificância é incompatível com a figura da posse de entorpecente para uso.

Não se pode olvidar que o legislador, ao editar a Lei nº 11.343/2006, optou por abrandar as sanções cominadas ao usuário de drogas, afastando a possibilidade de aplicação de penas privativas de liberdade e prevendo somente as sanções de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, conforme os incisos do artigo 28, de molde a possibilitar a sua recuperação. Vale dizer, a intenção do legislador foi a de impor ao usuário medidas de caráter educativo, objetivando, assim, alertá-lo sobre o risco de sua conduta para a própria saúde, além de evitar a reiteração do delito.

Nesse contexto, em razão da política criminal adotada pela Lei nº 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas.

A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Vale dizer, o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência, sendo, por isso mesmo, irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou do próprio indivíduo.

Assim, não se pode aplicar o princípio da insignificância ao delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sobretudo ao caso dos autos, sob pena de se tornar sem valia o dispositivo legal em comento e de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora.

Confira-se:

"Posse de entorpecente para uso. Artigo 28, da Lei n.º 11.343/06. Réu surpreendido por policiais no momento em que adquiria uma pedra de "crack". Confissão do acusado respaldada pelos relatos dos policiais responsáveis pela diligência. Prova hábil. Condenação de rigor. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Pena de prestação de serviços à comunidade adequada. Apelo improvido, afastada a matéria preliminar"(TJ/SP; Apelação 0021406-15.2011.8.26.0577; Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/05/2013).

Nesses termos, passo à dosimetria da medida.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena em advertência sobre os efeitos das drogas.

Observo que no caso é desnecessária punição maior do que advertência, já que ficou

o réu preso provisoriamente durante o processo, o que trouxe mais sofrimento e motivação para repensar a conduta, do que qualquer outra pena alternativa seria capaz.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO

1 - o réu DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DONATO, RG: 57727053, nascido em 10/04/1999, natural de Presidente Prudente - SP, filho de DERIVALDO LOURENCO DONATO e ANDRELISA PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso nas penas da artigo 28 da Lei das Contravenções Penais.

Determino a imediata restituição para o réu do numerário apreendido nos autos.

Determino a destruição da lâmina apreendida nos autos. Oficie-se de imediato.

Custas pelo réu.

Publique-se,

Registre-se,

Comunique-se e

Intimem-se.

Presidente Prudente, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA